

1502338-19.2020.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: NAIRA BLANCO MACHADO

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... em alegações finais, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação de regime inicial semiaberto.

Oportuno ressaltar que a incidência de uma causa de aumento não é óbice ao reconhecimento de tráfico privilegiado.

A propósito:

Apelação Tráfico interestadual em transporte coletivo Conduta de transportar, para o tráfico, 24 tijolos de maconha ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

1ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja - SP - cep 07400-000

1502338-19.2020.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502338-19.2020.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE TOMAZ DE SOUZA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO

Vistos.

FELIPE TOMAZ DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso V da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 13 de novembro de 2020, por volta das 17h15min, na Rodovia Presidente Dutra (BR 116), 204, sentido SP/RJ, Jardim Jóia, nesta Comarca, o acusado, trazia consigo, para inequívoco fim de entrega a consumo de terceiros, drogas, quais sejam, 01 (um) tijolo de cocaína, com massa bruta de 1.039,58 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a exordial acusatória, os policiais rodoviários federais realizavam fiscalização de rotina na praça do pedágio de Arujá, quando, em dado momento, passou pelo local um ônibus de viagem da Viação Kaissara com destino São Paulo/SP a Vitória/ES e, em razão da incidência de apreensão de drogas para este destino, decidiram fiscalizá-lo.

Os agentes ingressaram no interior do coletivo e passaram a entrevistar os passageiros, átimo em que o acusado demonstrou certo nervosismo, o que motivou a abordagem e efetivação de buscas.

Felipe trazia consigo, embaixo de seu assento, uma mochila de cor preta, em cujo

interior havia uma bexiga, contendo algo. Após rasgar a bexiga, foi encontrado um tijolo de substância entorpecente, mais precisamente cocaína.

Ao ser indagado, informalmente, o acusado admitiu que estava transportando os entorpecentes e asseverou que havia recebido a droga no Município de Osasco/SP e desembarcaria no Município de Iconha/ES, onde receberia orientações de como proceder a entrega da substância, pelo que auferiria a quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais) (fls. 84/87).

Auto de prisão em flagrante (fls. 01). Boletim de ocorrência (fls. 06/09). Auto de exibição e apreensão (fls. 10). Laudo químico-toxicológico (fls. 36/38 e 206/208). Folha de antecedentes (fls. 32/34 e 180).

Em análise da prisão preventiva esta foi convertida em prisão preventiva (fls. 43/46).

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar (fls. 111/118).

Foi recebida a denúncia em 10 de maio de 2021 (fls. 144/145).

Foram indeferidos os pedidos de revogação da prisão preventiva e reanalisada a manutenção da prisão (fls. 197/198, 209/210, 232/233).

Sobreveio resposta à acusação (fls. 213/223).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu ao final (fls. 228/229, 257 e 279/281).

O Ministério Público apresentou alegações finais, postulando a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Na dosimetria pleiteou a exasperação da pena-base por conta da quantidade das drogas. Na segunda fase presente a atenuante da confissão espontânea. Na terceira fase pleiteou a aplicação da majorante do artigo 40, inciso V e concordou com a aplicação do redutor do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas no patamar mínimo de 1/6. Pugnou pela aplicação do regime semiaberto e pela não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 288/295).

A defesa, por seu turno, discorreu sobre a conduta pessoal do réu. Pugnou pelo afastamento da causa de aumento pois a entrega da droga ocorreria numa cidade do interior do Estado de São Paulo. Argumentou que se trata de tráfico privilegiado, devendo ser aplicado o redutor ao réu no patamar máximo de 2/3. Na dosimetria requereu a fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da atenuante da confissão. Pugnou pela fixação do regime aberto para cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 297/307).

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A presente ação penal comporta procedência.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, laudo toxicológico, demais documentos e prova oral produzida.

A autoria segue a mesma sorte.

Passo à análise da prova oral.

A testemunha Fabio Junior, policial rodoviário federal, disse não recordar dos fatos.

A testemunha Carlos Eduardo, policial rodoviário federal, declarou que estavam em fiscalização de rotina no município de Arujá, km 204 da Rodovia Presidente Dutra, quando abordaram um coletivo da Viação Itapemirim, com itinerário São Paulo - Vitória. Aduziu que trabalham no grupo de operação com cães, efetuam tanto a fiscalização dos bagageiros inferiores, quanto da parte superior onde os passageiros ocupam as vagas. Contou que na fiscalização da parte superior, quando chegaram no passageiro da poltrona 27, Felipe, realizaram entrevista e na fiscalização da bagagem encontraram um tablete envolto com uma bexiga. Falou que ao rasgar a bexiga encontraram um tablete e ao rasgá-la verificaram que se tratava de entorpecente. Observou que Felipe admitiu que estava transportando entorpecente de São Paulo até uma cidade chamada Iconha do Espírito Santo e que receberia cerca de mil reais para estar fazendo o serviço. Esclareceu que Itapemirim e Kaissara são as mesmas empresas, eles compartilham veículos, são os mesmos donos. Aduziu que o rapaz abordado é o que está em audiência. Externou que já tem experiência no

trabalho de fiscalização de coletivos e a linha é contumaz no tráfico de drogas interestadual, assim como outras linhas de Rio de Janeiro – São Paulo, Vitória da Conquista, entre outras.

O réu Felipe afirmou que tem 25 anos, trabalhava como ferramenteiro e vendedor, ganhava setecentos reais por mês, estudou até o segundo grau, não é casado e não tem filhos, nunca foi processado antes. Declarou que realmente chegou a cometer o crime, pegou o tijolo de cocaína para levar mediante uma proposta feita por uma dívida que tinha beirando mil reais com um traficante. Aduziu que desde os 16 anos é usuário de drogas, usava muita cocaína, teve um tempo que parou de ir na biqueira e resolveu pegar com um contato, aí a dívida foi crescendo. Falou que não foi obrigado a ir, mas era melhor que fizesse, recebeu a proposta de levar a droga ao interior de São Paulo, dentro do ônibus, ia parar numa parada de ônibus e entregar a droga. Frisou que recebeu orientação para entregar a droga no interior de São Paulo. Noticiou que ia ganhar mil reais se entregasse a droga. Explanou que a passagem comprada realmente era para Vitória, mas ia descer no interior de São Paulo, entregar a droga numa parada e seguir viagem no mesmo ônibus até uma rodoviária próxima para retornar para São Paulo. Mencionou que ia quitar a dívida e ia sobrar um pouco, então de certa forma ia lucrar um pouco. Disse não recordar do valor do celular porque ganhou de sua irmã, e não passou por sua cabeça vender o celular ou a mochila para pagar a dívida, achou melhor fechar o acordo, seria mais fácil e rápido. Informou que quem ofereceu o acordo foi uma pessoa que mora perto de sua casa, mas não quer informar o nome. Explanou que uma pessoa iria entrar em contato por celular e orientar onde deveria ser entregue a droga. Comentou que sofreu ameaça indireta para entregar a droga.

Essa foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Ao cabo da instrução processual, restou demonstrado que o réu praticou o delito de tráfico que lhe foi imputado na denúncia.

De início, convém destacar que o depoimento do policial Carlos Eduardo corroborou o quanto descrito na denúncia, apontando que o réu estava no veículo coletivo que ia de São Paulo com destino ao Espírito Santo, sendo abordado, ocasião em que foram encontradas drogas numa bexiga que estava no interior de uma mochila.

O réu, por sua vez, confessou parte dos fatos, admitindo que foi cooptado por um traficante a quem devia para efetuar o transporte da droga, tendo afirmado que iria entregar os entorpecentes no interior de São Paulo, e que o local exato lhe seria orientado durante a viagem, recebendo ao final mil reais pela entrega.

As versões do réu e da acusação, na maioria dos pontos, acabam se encontrando.

Assim, em relação ao transporte da droga pelo réu, no veículo coletivo, não subsistem dúvidas.

O exame toxicológico confirmou a natureza entorpecente das drogas localizadas com o acusado. Cabe salientar que o réu afirmou que sabia estar transportando drogas.

O flagrante é inquestionável e as palavras coerentes e incriminatórias dos policiais são suficientes, haja vista que estão em conformidade com as demais provas dos autos, mormente ante a versão confessional apresentada pelo réu.

É importante salientar que em delitos de tráfico de drogas, cometidos, normalmente, na clandestinidade, a prova, em regra, é construída com base nos depoimentos dos policiais, que de modo geral, são suficientes a demonstrar a culpabilidade de um réu, desde que em consonância com as demais provas carreadas aos autos. E no caso dos autos, o conjunto probatório é robusto e idôneo para o reconhecimento da culpabilidade do réu, porque ao lado dos depoimentos policiais, há a apreensão do entorpecente na mochila de propriedade do réu, circunstância que não foi por este negada.

A tese defensiva de que a confissão não bastaria para a condenação do acusado não merece prosperar, uma vez que o réu indicou, em seu interrogatório judicial, inclusive os motivos que o levaram a aceitar o transporte de droga (alegando que aceitou por estar devendo a um traficante e por precisar de dinheiro), apresentando relato coeso, o que, aliado aos testemunhos policiais, constitui, como já mencionado, conjunto probatório suficiente à prolação de um decreto condenatório em seu desfavor.

Outrossim, inexistente qualquer causa excludente de ilicitude ou que isente o réu de

pena.

No mais, a ação foi culpável, reprovável, pois o réu era (e ainda é) ao tempo da conduta imputável, tendo consciência da ilicitude de suas ações. Não há, portanto, qualquer causa excludente da culpabilidade.

Nesse contexto, de rigor se torna a condenação do acusado pelo delito de tráfico. Do mesmo modo, comporta acolhimento o reconhecimento de causa de aumento de pena do art. 40, V, da Lei de Drogas, pois o ônibus em que o réu estava se dirigia para o Estado do Espírito Santo.

A alegação do réu, no sentido de que se dirigia ao interior do Estado de São Paulo não convence, carecendo de provas em tal sentido, pois como já se referiu, o itinerário do transporte coletivo no qual o acusado se encontrava era de São Paulo até o Espírito Santo.

O que se infere, portanto, da colheita da prova oral é que efetivamente o acusado realizava o transporte de drogas com destino a Vitória/ES, para entrega a terceiros.

Assim, plenamente viável o reconhecimento da causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, estando comprovado nos autos que o réu transportava entorpecentes para outro Estado da Federação, como descrito na denúncia.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – TRANSPORTE INTERESTADUAL – DECOTE DO INCISO III DO ARTIGO 40 DA LAT. I. Embora o sucesso no apelo possa não ser capaz de trazer alteração na pena, o réu possui interesse recursal em ver-se condenado apenas pelos atos que realmente praticou. II. A elevação da pena conforme o lugar do cometimento do crime tem por escopo punir com mais rigor aqueles que se valem da aglomeração de pessoas para disseminar a droga com maior facilidade e agilidade. III. A utilização de ônibus interestadual apenas para transportar o entorpecente para outro Estado da Federação insere-se na figura do inciso V do artigo 40 da LAT. IV. Recurso desprovido. (TJ-DF - APR: 20140111384435, Relator: SANDRA DE SANTIS, Data de Julgamento: 17/09/2015, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/09/2015 . Pág.: 72).

Não obstante, a despeito da demonstração da culpabilidade do acusado, algumas considerações merecem ser tecidas, e que carecem de valoração, especialmente para fins de individualização da pena.

Com efeito, conquanto as provas produzidas não autorizem, como já explanado sobejamente, um decreto absolutório em favor do acusado, de outro lado, os elementos amealhados aos autos não permitem concluir pela existência de um comportamento delitivo contumaz, reiterado.

No caso em questão, o acusado é um indivíduo com 25 anos de idade, sem antecedentes criminais (fls. 32/34 e 180), que comprovou nos autos por meio documental que exercia, ao menos ao tempo da sua prisão, labor regular, além de possuir residência fixa e se dedicar a cursos de formação (fls. 119/122).

Assim, considerando esses elementos, o histórico do acusado e a sua vida pregressa, mas também as circunstâncias do caso, não é desarrazoado concluir que o acusado atuou como "mula" do tráfico.

Também não se deve olvidar que, segundo relato dos policiais, o réu manifestou certo nervosismo durante a abordagem, demonstrando, com isso, certa inexperiência na prática do delito. Em outras palavras, o acusado pareceu portar-se como alguém que de fato não estaria habituado com a dinâmica delituosa.

Outrossim, é preciso destacar que com o acusado não foram encontrados quaisquer outros objetos, tais como anotações, cadernos de contabilidade, e outros que pudessem vinculá-lo, de uma forma mais estável ou permanente, ao comércio espúrio. Também não foi localizado qualquer armamento ou quantia expressiva de dinheiro em seu poder.

Com o acusado foram encontrados apenas a mochila com a droga e um aparelho celular. No mais, a despeito da quantidade de droga apreendida no veículo do acusado ser considerável, também não é absurdamente expressiva (981,95 gramas - fls. 37) quando comparada a outras apreensões.

E muito embora tal droga tenha provável origem em organização criminosa mais estruturada, conquanto esta não tenha sido minimamente identificada, o simples fato de o réu ter transportado a droga, não constitui, à vista das circunstâncias constantes dos autos, elemento probatório idôneo suficiente a concluir, com a segurança necessária, que o acusado seria efetivamente integrante de organização criminosa.

Tal conclusão vem reforçada também pela oitiva dos policiais e pela versão do réu, concluindo-se que o averiguado receberia em pagamento pelo transporte da droga a quantia de mil reais, o que termina por indicar, no entender deste juízo, uma atuação eventual do acusado.

Com efeito, da análise dos autos, só se pode extrair que o réu agiu como transportador eventual, mormente diante de seu histórico pessoal escorreito, não sendo possível afirmar que o acusado integre organização criminosa, pois para que isto fique manifesto, é necessário que se verifique espontânea vontade de integrar a associação, além de fazer da criminalidade seu meio de vida principal, com habitualidade criminosa, não sendo este o caso de pessoas que são ocasional ou eventualmente cooptadas por tais organizações a praticarem delitos específicos. Assim, à vista das circunstâncias explanadas, não sendo possível concluir ser o réu integrante de organização criminosa, não haveria motivos idôneos a afastar a incidência do parágrafo 4º do art. 33 da lei 11.343 ao caso em questão. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso especial da acusação para afastar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Narra o impetrante, em síntese, que: a) o paciente foi condenado em primeiro grau à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas; b) entre a sua prisão em flagrante e o julgamento de recurso de apelação em que se buscava o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, cumpriu-se integralmente a pena, tendo sido extinta sua punibilidade; c) sobreveio, então, o ato coator, dando-se sequência à execução da pena privativa de liberdade, redimensionada para 5 anos de reclusão. Busca-se a detração com a alteração do regime de continuação da execução. É o relatório. Decido. 1. Cabimento do habeas corpus: A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: "O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal." (HC 128693 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) "O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal." (HC 123430, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) "(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior." (HC 86367, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) No caso concreto, extrai-se dos autos (eDOC 10, p. 74) que o ato coator transitou em julgado em 15.3.2018. Assim, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. 2. Contudo, no que se refere ao afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, verifico a existência de constrangimento ilegal, passível de conhecimento de plano. No caso concreto, o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais decidiu pela manutenção do redutor com base nos seguintes fundamentos (eDOC 10, pp. 65-66): Em relação à terceira fase de aplicação da pena, pleiteou o Parquet o afastamento da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, ao argumento de que o acusado se dedicava às atividades criminosas. Sem razão o órgão acusador. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que embora Jean Carlos tenha sido surpreendido em flagrante após ter sido

constatado pelo serviço de inteligência da Polícia Federal o transporte da droga, nada nos autos menciona a respeito de outras atividades ilícitas por ele praticadas. Não há informações nos autos no que tange às investigações anteriormente realizadas, limitando-se os agentes policiais a indicar a respeito apenas da apreensão. Ademais, a meu ver, é dever da acusação trazer para os autos, de forma inequívoca, as informações que têm o condão de incrementar as penas, não havendo, no presente feito, qualquer anotação neste sentido. Assim, não havendo provas suficientes de que o acusado fazia do comércio ilícito seu meio de vida, dedicando-se à atividade criminosa, é possível afirmar que o caso presente se revele como uma ocorrência isolada, o que permite a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas. 2.1. Como se nota, no que atine ao afastamento do redutor, a motivação do Superior Tribunal de Justiça está centrada na expressiva quantidade de droga, superior a 108 kg (cento e oito quilogramas) de cocaína, bem como na constatação da existência de “acordo de recebimento da importância de R\$ 2.000,00 a ser paga por terceiro” para transporte daqueles tabletes, tudo a indicar a dedicação do paciente a atividades criminosas (eDOC 10, pp. 41-42). Não obstante o alto poder lesivo do entorpecente apreendido, não é possível fazer tal ilação sem o suporte de outros elementos fático-probatórios. Segundo a jurisprudência do STF, “[a] quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa” (RHC 138.715, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 09.06.2017). Com efeito, a quantidade e a natureza da droga apreendida não são fatores que, isoladamente, impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, notadamente se evidenciada, como no caso dos autos, a mera condição de transportador do paciente, bem como, a partir do que as decisões proferidas permitem observar, o preenchimento dos demais requisitos previstos na minorante. Afirmou o TJMG que “nada nos autos menciona a respeito de outras atividades ilícitas por ele praticadas”. O paciente foi flagrado transportando expressiva quantidade de cocaína, conduta pela qual receberia remuneração. Contudo, à míngua de outros elementos probatórios, não há qualquer indicativo de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente. A Segunda Turma do STF tem posição firme no sentido de que a condição de “mula” ou a mera alusão ao fato de ter efetuado o transporte de entorpecentes (ainda que entre Estados da Federação), por si só, não impede a incidência da minorante. Para fins de individualização da pena, a singela alusão genérica à importância dos transportadores na estrutura de uma suposta organização criminosa não preenche o figurino exigido pela ordem constitucional. Na mesma linha: “Incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas afastada pelas instâncias de mérito com amparo em mera conjectura ou ilação de que os pacientes integrariam organização criminosa, já que recrutados para transportar drogas ao exterior (mulas do tráfico). Inexistência de base empírica idônea. Constrangimento ilegal configurado. Habeas corpus concedido de ofício. (...) O exercício da função de mula, embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga.” (HC 124107, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 04.11.2014, grifei).

“PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO NA FRAÇÃO DE 1/3. PRECEDENTES. 1. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar pelo menos um dos critérios, que são autônomos, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. Nesse juízo, não se pode ignorar que a norma em questão tem a clara finalidade de apenar com menor grau de intensidade quem pratica de modo eventual as condutas descritas no art. 33, caput e § 1º, em contraponto ao agente que faz do crime o seu modo de vida, o qual, evidentemente, não goza do referido benefício (cf. justificativa ao Projeto de Lei 115/2002 apresentada à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação). 2. No caso, o Tribunal de

apelação afastou a referida minorante com base em argumentos genéricos e teóricos, desprovidos de qualquer elemento contido nos autos, senão no fato de a paciente ter sido condenada pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas. Por outro lado, a sentença condenatória afirmou, de forma segura, a inexistência de prova apta a justificar a negativa da causa de diminuição. Precedentes. 3. Ordem parcialmente concedida." (HC 124022, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). Dito isso, não visualizo qualquer fundamento hábil a negar a incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 ao paciente. 4. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem de ofício para restabelecer a minorante, devendo a pena do paciente seguir os moldes fixados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e à Vara de Execuções Criminais da Comarca de Juiz de Fora com cópia do inteiro teor desta decisão. Comunique-se, outrossim, ao Superior Tribunal de Justiça, para ciência. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. Ministro Edson Fachin Relator Documento assinado digitalmente. (STF - HC: 181268 MG - MINAS GERAIS 0086299-90.2020.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 14/02/2020, Data de Publicação: DJe-035 19/02/2020). (grifos nossos)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AGENTE NA CONDIÇÃO DE "MULA". PLEITO DE DECOTE DESSA MINORANTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A orientação jurisprudencial desta Casa, na linha do entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que "o fato de o agente haver atuado como 'mula' no transporte da droga não pode - como numa relação, pura e simples, de causa e efeito - levar à conclusão de que ele seria integrante de organização criminosa e, como tal, não seria merecedor da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A diferenciação deve ser feita, inequivocamente, caso a caso, com base em elementos objetivos e concretos dos autos (REsp n. 1.365.002/MS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017). 2. No caso dos autos, o colegiado estadual, respeitando os critérios legais estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e, ainda, com observância aos pormenores da situação concreta, entendeu que inexistiam nos autos provas que demonstrassem a dedicação do agravado às atividades criminosas ou de que integrasse organização criminosa, embora tenha sido apreendida grande quantidade de entorpecente, qual seja, mais de 32kg (trinta e dois quilos) de maconha. 3. Nesse contexto, para que fosse possível a análise da pretensão recursal de decote dessa minorante, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1532159 MT 2019/0190378-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020). (grifos nossos).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME QUE DENOTA HABITUALIDADE DELITIVA. EVIDENCIADA AINDA A PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em 13 de novembro de 2019, com pedido de liminar, em favor de Pedro Eduardo Costa de Oliveira, em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE. 2. Compulsando os fólios, depreende-se que não assiste razão à defesa, 1) seja porque entendo que a imputação realizada pelos órgãos persecutórios da integração do paciente à organização criminosa é suficiente para comprovar o seu perigo à ordem pública, em razão da habitualidade criminosa ser inerente a esse tipo penal; 2) seja porque entendo estar presente nos autos provas da sua periculosidade concreta; Senão vejamos. 3. A organização criminosa está relacionada à atuação da delinquência estruturada, que

visa afrontar diária e habitualmente bens jurídicos fundamentais para o Estado Democrático de Direito. Assim sendo, o indivíduo que decide por livre e espontânea vontade integrar determinada associação, deve ser considerado como uma pessoa que faz da criminalidade seu meio de vida principal. Não estamos aqui a tratar das pessoas que ocasionalmente são cooptadas ou coagidas por essas organizações a praticarem delitos específicos – como, por exemplo, nos casos das 'mulas do tráfico' –, mas sim daquelas que decidiram fazer parte permanentemente da organização, fazendo das práticas criminosas verdadeiras profissões. 4. Ora, a habitualidade criminosa é condição de existência, portanto, condição sine qua non de uma organização criminosa, sendo a jurisprudência uníssona quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva dos réus, cujos autos evidenciam a prática habitual de delitos. Precedentes do STJ. 5. Ainda que se diga que tal indivíduo não detém nenhuma função administrativa, de comando ou de gerência, ele é parte indispensável para o todo harmônico funcionar; e ainda se beneficia, mesmo que indiretamente, do produto oriundo das atividades criminosas diárias e habituais da empresa do crime. (...) 11. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de habeas corpus, nº 0632586-38.2019.8.06.0000, ACORDAM os desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por maioria, em CONHECER do habeas corpus impetrado, mas para DENEGAR a ordem, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 21 de janeiro de 2020 MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Relator Designado (TJ-CE - HC: 0632586382019060000 CE 0632586-38.2019.8.06.0000, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 21/01/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2020). Grifo Nosso.

Tratando-se de acusado primário, deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois o réu ostenta bons antecedentes e inexistente nos autos comprovação suficiente de que se dedique a atividade criminosa, ficando demonstrado pelas provas acostadas aos autos que o réu atuou evidentemente como "mula". Demais disso, a quantidade de drogas, embora seja considerável, não obsta o reconhecimento da minorante. Nesse sentido, os arestos abaixo colacionados.

EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MULA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Para verificar a adequação da causa de diminuição ao caso concreto, indispensável observar tanto as condições individuais do agente quanto as da conduta em concreto praticada, de todo incabível a concessão do benefício em caso de reincidência, maus antecedentes, dedicação a atividades criminosas ou participação em grupo destinado a esse fim. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que 'o exercício da função de mula, embora indispensável para o tráfico internacional, não traduz, por si só, adesão, em caráter estável e permanente, à estrutura de organização criminosa, até porque esse recrutamento pode ter por finalidade um único transporte de droga', porquanto 'descabe afastar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 com base em mera conjectura ou ilação de que os réus integrariam organização criminosa' (HC 124.107/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 24.11.2014). 4. Na hipótese, proporcional e razoável a fixação da minorante no patamar de 2/3 (dois terços), considerada a inexistência de circunstância ou fato desabonador ensejador de aplicação de fração menor. Precedentes: HC 132.459/SP, Rel. Min. Ricardo



Lewandowski, 2ª Turma, votação unânime, DJe 13.02.2017; HC 131.918/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, votação unânime, DJe 02.3.2016; e HC 123.534/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, votação unânime, DJe 10.10.2014. 5. Observados os parâmetros estabelecidos no HC 97.256/RS e no HC 111.840/ES desta Suprema Corte e consideradas a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, no patamar de 2/3 (dois) terços e "a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis", possível a fixação de regime prisional mais brando – aberto –, e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. 6. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com concessão de ofício da ordem, para determinar que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região proceda a nova dosimetria da pena, mediante a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, no patamar de 2/3 (dois terços), e reexamine, se o caso, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (STF - HC: 129449 SP - SÃO PAULO 0004774-62.2015.1.00.0000, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 14/03/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-088 28-04-2017). (grifos nossos)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AGENTE NA CONDIÇÃO DE "MULA". AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO INFERIOR AO MÁXIMO ACERTADA. 1. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem expressamente fundamentou a majoração da pena-base em 2 anos, com fundamento na natureza e quantidade de entorpecentes - 1920g de "cocaína", nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e art. 59 do CP, encontrando-se devidamente justificada e proporcional às especificidades do caso versado. 3. Para a aplicação da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso em concreto. O legislador, entretanto, não definiu os critérios a serem adotados pelo magistrado para a escolha do percentual de redução da pena. 4. No presente caso, a opção pela fração de 1/6 foi devidamente justificada no fato de o acusado ter contribuído com organização criminosa, agindo na condição de "mula", o que se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra justificativa nas peculiaridades da ação criminosa. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1013343/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017).

Ainda, o próprio órgão acusador requereu, em alegações finais, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com aplicação de regime inicial semiaberto.

Oportuno ressaltar que a incidência de uma causa de aumento não é óbice ao reconhecimento de tráfico privilegiado.

A propósito:

Apelação Tráfico interestadual em transporte coletivo Conduta de transportar, para o tráfico, 24 tijolos de maconha (22,530 Kg) Pleito absolutório por fragilidade probatória - Inadmissibilidade Autoria e materialidade comprovadas - Depoimentos dos policiais firmes e coerentes, os quais consoam com a confissão judicial da ré Validade para embasar decreto condenatório Circunstâncias da prisão e quantidade de entorpecentes a demonstrar a destinação da droga à venda Provas que bem demonstram as causas de aumento do artigo 40, III e V, da Lei de Drogas Desnecessidade de que

o tráfico tenha como alvo pessoas do transporte coletivo - Penas, todavia, que comportam alteração Quantidade que, por si só, não afasta a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas - Ré primária - Não comprovação de envolvimento com atividades criminosas ou organização criminosa - Quantidade a impedir, todavia, a redução no patamar máximo, mostrando-se ajustada a redução mínima de um sexto Abrandamento do regime prisional, do fechado para o semiaberto Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500089-91.2019.8.26.0483; Relator(a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Venceslau - 3ª Vara; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021).

Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR o réu FELIPE TOMAZ DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, caput c.c.art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06.

Apurada a responsabilidade penal, passo a dosar a pena de condenação.

Circunstâncias judiciais

Assim, primeiramente, no tocante às circunstâncias judiciais, verifico que o réu agiu com a culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar nesse sentido. Não há nos autos elementos concretos que permitam uma valoração da sua personalidade. O réu não possui maus antecedentes (fls. 32/34 e 180). O motivo do delito se constituiu pela obtenção do lucro fácil, que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito. Nada há, em concreto, que desabone a sua conduta social. As consequências do crime não se mostraram de maior monta. As circunstâncias, por sua vez, são desfavoráveis ao acusado, já que o fato envolveu a apreensão de considerável quantidade de cocaína (981,95 gramas - fls. 37), tratando-se de entorpecente, a princípio, com maior poder lesivo quando comparado a outras substâncias ilícitas. Diante dessa circunstância desfavorável, fixo a pena base em 06 (seis) anos, e 03 (três) meses de reclusão e 625 dias-multa, no menor valor legal.

Ausentes circunstâncias agravantes.

Incide a atenuante da confissão, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d" do CP, visto que foi utilizada para a formação do convencimento do julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ, passando a pena para 05 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 dias-multa.

Presente a causa de aumento do tráfico interestadual, art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, aumentando a pena em 1/6, passando para 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 606 dias-multa.

Incide, como já asseverado alhures, a causa de diminuição de pena do § 4º, art. 33, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é primário, não possuindo antecedentes, não havendo ainda provas suficientes de que se dedique a atividades criminosas ou de que integre organização criminosa, não tendo sido produzida pela acusação nenhuma prova de vínculo aprofundado e estável com o comércio espúrio, para cujo reconhecimento seria necessária a existência de prova cabal neste sentido.

Neste ponto, vale mencionar a manifestação de César Dário Mariano:

Presentes os requisitos previstos na norma a diminuição da pena é obrigatória, não ficando ao alvedrio do Juiz operar a redução ou não. Embora a norma empregue a expressão "as penas poderão ser reduzidas", não se trata de atividade discricionária do Juízo, mas de direito subjetivo do acusado. Aliás, a primariedade e bons antecedentes deverão ser demonstrados pelo acusado, ao passo que caberá ao Ministério Público o ônus de provar que o réu se dedica à atividade criminosa ou que pertence à organização criminosa. Não cabe ao réu a prova de fatos negativos, mas a quem alega, no caso, o Ministério Público.

(...) Dedicar-se a atividades criminosas pressupõe reiteração de condutas tipificadas como crime, ou seja, habitualidade no cometimento de delitos. Tal circunstância poderá ser demonstrada por meio de folhas de antecedentes criminais, certidões cartorárias, cópias de outros processos, testemunhas, ou seja, qualquer meio hábil a provar a vida criminosa do acusado. Como a norma não diz qual espécie de atividade criminosa poderá ser qualquer uma, desde que, obviamente, não se trate

de delitos culposos, que pressupõem ausência de vontade.

A norma visa a impedir a redução da pena para aquele que de forma habitual e deliberada pratica qualquer espécie de crime. Com efeito, aquele que faz da vida criminosa seu modo de vida não é merecedor do redutor. (Silva, César Dario Mariano da Lei de drogas comentada / César Dario Mariano da Silva. -- 2. ed. -- São Paulo : APMP - Associação Paulista do Ministério Público, 2016).

Em sentido semelhante:

"A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena" (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).

Outrossim, conforme explanado anteriormente, a quantidade de drogas, por si só, não pode resultar na interpretação de que o réu faz do tráfico seu meio de vida ou integra organização criminosa. Nesse sentido, em complemento aos arestos já colacionados, seguem os julgados abaixo:

Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (132,85 KG). DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ABSOLVIDA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE.

I - A grande quantidade de entorpecente, apesar de não ter sido o único fundamento utilizado para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, foi, isoladamente, utilizado como elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa e, assim, negar-lhe o direito à minorante.

II - A quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes.

III - É patente a contradição entre os fundamentos expendidos para absolver a paciente da acusação da prática do delito tipificado pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 e aqueles utilizados para negar-lhe o direito à minorante constante do art. 33, § 4º, do mesmo diploma legal. Precedentes.

IV - Recurso ordinário ao qual se dá provimento, em parte, para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, e determinar que o juízo a quo, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. (STF. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS 138.715 MATO GROSSO DO SUL.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. SÚMULA 7/STJ. CONTRIBUIÇÃO DO AGENTE COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NA CONDIÇÃO DE MULA. APLICAÇÃO DO REDUTOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Assentado pelo Tribunal a quo, soberano na análise dos fatos, que inexistia prova da dedicação da acusada à atividade criminosa, a alteração desse entendimento enseja o revolvimento do conteúdo probatório dos autos, inadmissível em recurso especial (Súmula 7/STJ). 2. No caso, conforme se extrai dos excertos, o Tribunal de origem, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, concluiu motivadamente pela aplicação do redutor no patamar de 1/3, tendo em vista que a atuação da ré era típica de 'mulas do tráfico', embora tenha sido apreendida com grande quantidade de drogas (33 kg de maconha). 3. O atual entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria é no sentido de que a simples atuação como "mula", por si só, não induz que o réu

integre organização criminosa, de forma estável e permanente, não constituindo, portanto, fundamento idôneo para afastar a aplicação do redutor em sua totalidade, tratando-se de meras ilações, presunções ou conjecturas, até porque pode se tratar de recrutamento único e eventual (Precedentes.) 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1776471 MS 2018/0285250-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AGENTE NA CONDIÇÃO DE "MULA". REDUÇÃO EM 1/3. PROPORCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. 2. Hipótese em que a instância antecedente, atenta às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos - 153 kg de cocaína - para elevar a pena-base em 3 anos e 4 meses acima do mínimo legal, o que não se mostra desproporcional. 3. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 4. A ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/3, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Logo, devidamente motivada a escolha do patamar de redução, a alteração desse quantum é questão afeta à atividade discricionária do julgador, que só pode ser revista quando verificada sua desproporcionalidade, o que não é o caso dos autos. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 495680 SP 2019/0058485-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2019)

Diante disto, cabível a redução à razão de 2/3, já que somente a quantidade de drogas não é elemento suficiente a afastar a minorante ou mesmo modular a fração do benefício. Demais, a natureza e quantidade da droga já foram consideradas por ocasião da valoração das circunstâncias judiciais. Nesse sentido, o recente julgado do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA E, PORTANTO, NÃO SE PRESTAM PARA JUSTIFICAR O AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAR A FRAÇÃO DESSE BENEFÍCIO. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (RECURSO ESPECIAL Nº 1925096 - SP - RELATORA: MINISTRA LAURITA VAZ - Brasília, 02 de agosto de 2021). (grifos nossos).

Assim, diminuo a pena em 2/3, ficando o réu definitivamente condenado à pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) dias de reclusão cumulada com 202 dias-multa, no mínimo legal, pena esta que torno definitiva.

Do regime inicial de cumprimento de pena e alternativas penais

O parágrafo 4º do art. 33 da lei 11.343/06 de forma louvável, admitiu em casos como o ora analisado, a possibilidade de redução da pena imposta ao acusado primário e de bons antecedentes em até 2/3. A previsão legal de uma causa de diminuição de pena nestas circunstâncias tratou de prestigiar da forma adequada o

princípio constitucional da individualização da pena, reconhecendo uma situação fática que salta aos olhos do operador do direito: o de que traficantes eventuais, de bons antecedentes e que nunca se envolveram em organizações criminosas não podem ser equiparados aos grandes comerciantes de drogas, verdadeiros empresários do tráfico, responsáveis por manter toda uma rede articulada de produção e distribuição de drogas, auferindo grandes lucros da atividade e fomentando o cometimento de outros tantos delitos gravosos. Como se vê, são duas espécies distintas de criminosos a justificar tratamentos diversos pela lei penal.

Estranhamente, o próprio dispositivo legal supra aludido, de forma incongruente, negava expressamente a possibilidade de substituição da pena privativa em pena restritiva de direito, afastando-se, desta feita, dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, e, como tal, do próprio princípio da individualização da pena que, de início, parecia pretender alcançar.

Não há dúvida, como mencionado alhures, que a reprovabilidade da conduta do traficante ocasional é menor do que a dos grandes traficantes de droga responsáveis por coordenar e alimentar a grande cadeia do tráfico ilícito de entorpecentes. Eis a razão pela qual a nova lei de drogas, de forma feliz, reconheceu a culpabilidade atenuada daqueles pequenos criminosos, permitindo uma razoável diminuição da pena que eventualmente lhe venha a ser imposta.

Todavia, a concretização da máxima da individualização da pena não se esgota na dosagem da quantidade de pena